

1500322-66.2022.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: João Carlos Germano

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... que internalizou diversos diplomas internacionais que visam reprimir severamente o tráfico de drogas. 4. O tráfico de drogas é reprimido pelo Estado brasileiro, através de modelo jurídico-político, em consonância com os diplomas internacionais firmados. 5. Os preceitos constitucionais sobre o tráfico de drogas e o respectivo confisco de bens constituem parte dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

3ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros - s/nº, Fórum Criminal

CEP: 12020-070 - Taubaté - SP

Telefone: (12) 2124-9113 - E-mail: taubate3cr@tjsp.jus.br

1500322-66.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500322-66.2022.8.26.0618

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Denis Costa Santos e outros

Justiça Gratuita

Réu Preso

Juiz de Direito: João Carlos Germano

Vistos.

DENIS COSTA SANTOS foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 10 de março de 2022, por volta das 17horas, na Rua Tenente Mauro Francisco dos Santos nº 140, nesta cidade e comarca de Taubaté, transportava, para fins de tráfico, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo afirma a acusação, na data dos fatos, fazendo uso da caminhonete da marca GM, modelo Montana LS, placas EYJ 7103, o réu transportava sobre o assoalho, no lado do passageiro, em uma mochila, 958,08g (novecentas e cinquenta e oito gramas e oito centigramas) de cocaína.

Com o réu foram localizados e apreendidos, ainda, 2.000 pequenos tubos plásticos do tipo "eppendorf", utilizados para a embalagem da droga para a venda no varejo, além da quantia de R\$ 91,00.

A droga foi regularmente apreendida (fls. 19/20) e submetida a exame de constatação prévia (fls. 23/24).

Busca, assim, a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

A denúncia foi recebida às fls.105/107.

Citado (fls. 140), o réu apresentou resposta escrita à acusação às fls. 145/149.

Designou-se audiência, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas e procedeu-se ao interrogatório do réu, colhendo-se alegações finais do Ministério Público e da Defesa.

O Ministério Público postulou a procedência do pedido, alegando que a autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas pelas provas existentes nos autos. Ressaltou que os depoimentos dos policiais foram coerentes e harmônicos, gozando de credibilidade suficiente para embasar a condenação. Além disso, afirmou que eles apresentaram declarações assertivas firmes, coesas e detalhadas, que não revelam contradições capazes de comprometer a sua credibilidade. Defendeu que, em que pese a negativa de autoria do réu, constatou-se que ele tentou se afastar do carro que conduzia quando percebeu a aproximação da viatura e chamou a atenção da população, visando a prejudicar a ação policial. Ademais, sua filha alegou que desconhecia a existência das drogas, na fase policial, todavia, indicou que seriam de um indivíduo chamado Alex Rodrigues, com quem manteve relacionamento amoroso, em juízo, sem fornecer informações para sua localização. Outrossim, mencionou que o réu apresentou justificativas para a posse do carro que não condizem com o conjunto probatório, bem como, conforme narraram os policiais, ele foi abordado, na posse do veículo, em diversas outras oportunidades. Na dosimetria, em sua primeira fase, vislumbrou circunstâncias desfavoráveis, tendo em vista a quantidade significativa de droga apreendida no interior do veículo, pleiteando a fixação da pena-se acima do patamar mínimo legal. Verificou, ainda, que o réu ostenta maus antecedentes. Na segunda fase, anotou a existência da agravante da reincidência, pedindo que o aumento seja aplicado superior a 1/6 em razão da multirreincidência. Afiançou ser inaplicável o redutor de pena previsto no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas. Diante das circunstâncias desfavoráveis, solicitou a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.

A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência do pedido. Enfatizou que, além de o réu, em seu interrogatório judicial, ter negado a imputação que lhe foi feita, sua versão foi corroborada por sua filha, que atribuiu os entorpecentes a um antigo namorado. A testemunha, ainda, asseverou que o réu, a exemplo dela e das demais pessoas que presenciaram a abordagem, foram vítimas de intimidação e de violência policial. Nesse cenário, afirmou que o réu somente acabou sendo autuado em flagrante delito em virtude da sua vida pregressa, com algumas máculas. Diante desses elementos, postulou sua absolvição como medida de rigor.

É o relatório.

Decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, por meio da qual o Ministério Público requereu a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 do Código Penal.

Não há questões preliminares a se enfrentar. As condições da ação estão presentes, assim como os pressupostos processuais, o que rende ensejo à apreciação do mérito.

É o caso de acolhimento do pedido condenatório.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.

1/2), boletim de ocorrência (fls.11/15), termo de depoimento (fls. 3/5), termo de declarações (fls.6/7), termo de interrogatório (fls.10), auto de qualificação, vida pregressa e BIC (fls.18), auto de exibição e apreensão (fls.19/20), auto de constatação preliminar (fls. 22/24), laudo definitivo de fls. 232/234 e pelos depoimentos colhidos em juízo.

Com relação à autoria, melhor sorte não assiste o acusado, em razão da robusta prova atribuindo a ele a prática do crime de tráfico de drogas.

A testemunha José Henrique Ribeiro, ouvida em juízo, relatou que receberam uma denúncia de que o réu estava na posse de arma de fogo, motivo pelo qual seu veículo estava sendo rastreado pelo projeto radar. Em uma abordagem anterior, ele havia fugido e abandonado um documento no carro. Nessa data, receberam pelo COI a localização dele e o acompanharam até o local da abordagem. Narrou que deram sinal de parada, mas este foi desobedecido. Alguns quarteirões depois, em frente a um lava-rápido, ele parou na via pública e desceu do veículo com a filha e o neto. Mencionou que ele tentou se evadir e começou a gritar, chamando a atenção dos populares, que intervieram a seu favor. Informou que solicitaram apoio, para que pudesse ser feita a vistoria do automóvel, onde encontraram, embaixo do banco do passageiro, os entorpecentes. Os itens estavam em uma embalagem do Mercado Livre, de fácil visualização. Não se recorda do endereço na embalagem. Ao ser indagado, ele assumiu a propriedade das drogas, porém, na Delegacia, negou. Alegou que já o conhecia, por uma abordagem anterior, mas nada de ilícito foi encontrado. O carro estava em nome da irmã dele. Negou que tenha acontecido perseguição. Citou que Kailaine também foi deslocada à Delegacia.

A testemunha Anderson Luiz Ribeiro da Costa, ouvida em juízo, relatou que estavam em patrulhamento de rotina, quando o veículo do réu foi identificado pelo sistema de radares, uma vez que estava sendo monitorado pela ocorrência de crime anterior. No momento o COI passou as informações de localização dele. No bairro em questão, deram ordem de parada e ele desceu, em frente a um lava-rápido, com uma mulher e uma criança. Mencionou que ele tentou se evadir e começou a gritar, chamando a atenção dos populares, que intervieram em seu favor. Inclusive, o filho dele, que estava no endereço, foi detido por desacato. Em razão disso, solicitaram apoio e procederam à vistoria do veículo. A mulher, filha dele, tentou remover alguma coisa do carro, oportunidade em que encontraram, dentro de uma embalagem do Mercado Livre, eppendorfs vazios e uma quantia de cocaína. Com Kailaine não foram encontrados entorpecentes. Posteriormente, foram até a residência do réu, para localizar mais drogas ou armas, mas nada foi encontrado. O celular e a carteira do réu foram devolvidos ao advogado. Ao ser indagado, o réu assumiu a propriedade dos entorpecentes, informando que seria recompensado com R\$ 100,00 e 25 pedras de crack. Na Delegacia, ele negou essa versão. Alegou que já o conhecia, por uma abordagem policial na qual ele havia fugido e abandonado um documento no carro. Em outra ocasião, ele foi abordado em um posto de gasolina e assumiu a posse de uma arma de fogo, para sua proteção, entretanto, não foram feitas diligências.

A testemunha Hiago de Oliveira Rodrigues, ouvida em juízo, informou que conhece o réu porque ele fazia carretos. No dia apurado, ele estava indo até seu lava-rápido prestar um serviço, para buscar um compressor. O filho dele era seu funcionário.

Ygor Vinicius dos Santos, ouvida em juízo, informou que é filho do réu. No dia apurado, estava trabalhando com Hiago. Seu genitor teria ido ao local para ajudá-los a comprar um compressor. Após a abordagem e vistoria do veículo, os policiais começara a agredir seu pai, motivo pelo qual interveio e sofreu lesões. Logo após foram deslocados a um endereço que não era de sua família. O veículo era alugado para fazer carretos. Negou ter visualizado os entorpecentes.

Kailaine Yasmin dos Santos, ouvida em juízo, informou que é enteada do réu. Relatou que tinha ido ao supermercado e estava esperando um Uber para ir embora, quando um

ex-namorado passou de moto e pediu que levasse seus pertences. Na ocasião, ele lhe entregou uma bolsa e duas sacolas, que estavam fechadas. Logo após, seu pai passou e fez o retorno, oferecendo carona. Eles se deslocaram para o lava-rápido, onde seu irmão trabalhava, pois, seu pai iria fazer um carreto. Ao descerem, os policiais apareceram e realizaram a abordagem, de maneira agressiva. Na revista veicular, eles abriram a bolsa e as sacolas, nas quais localizaram os entorpecentes. Mencionou que explicou aos policiais a origem dos itens, garantindo que seu genitor não tinha conhecimento. Imediatamente, foi liberada pelos policiais. Logo após, eles foram fazer as buscas na residência de seu irmão. Visualizou os policiais entregando o dinheiro para seu advogado. Na delegacia, escutou os policiais conversando, dizendo que não gostavam de seu pai. Perguntada, disse que seu ex-namorado se chama Alex Rodrigues. Justificou que estava bastante nervosa, por isso não mencionou essa versão na Delegacia.

O réu Denis Costa Santos, interrogado em juízo, asseverou que tem conhecimento da acusação e negou que seja verdadeira. Mencionou que tinha problemas com vício em drogas. Em determinada ocasião, ficou três dias nas ruas, consumindo entorpecentes. O veículo era de sua irmã e ele disponibilizou para ser usado em troca de drogas, mas sua irmã conseguiu recuperá-lo e vendê-lo. Sua vizinha comprou o carro e, por saber que ele usava para trabalhar, emprestou-lhe o automóvel. Afirmou que já passou por tratamento. No dia do posto de gasolina, estava abastecendo o carro para devolvê-lo, quando foi abordado e logo liberado. No dia apurado, foi até o lava-rápido que seu filho trabalhava para fazer um carreto. No caminho, deparou-se com sua filha e ofereceu-lhe uma carona. No endereço, foi novamente abordado pelos mesmos policiais, de forma violenta. No momento, eles começaram a agredir seu filho, razão pela qual solicitou ajuda aos transeuntes. Em seguida, eles se deslocaram até a residência de seu filho, invadindo-a. Kailaine foi liberada no local da abordagem. Logo após, foram todos conduzidos à Delegacia, onde os policiais apareceram com as sacolas e proferiram ameaças contra ele. Explicou que sua filha estava namorando um traficante, que deixou as sacolas com ela. Negou conhecimento sobre os entorpecentes. O celular era seu e de uso de seu neto. Questionado, disse que não contou essa versão ao delegado por ter sido ameaçado pelos policiais. Disse estar em união estável e tem 5 filhos; trabalha com carretos, com renda média de R\$ 200,00 por dia; tem outros processos por roubo.

Bem provadas a autoria e a materialidade.

Dispõe o artigo 33, caput, da Lei de Drogas:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:"

Verifica-se que a conduta do réu se enquadra no verbo transportar e trazer consigo drogas, previsto no núcleo do tipo, assim, configurada a traficância.

O réu foi preso porque tinha no interior de seu veículo as drogas posteriormente apreendidas, além dos eppendorfs para distribuir os entorpecentes em porções, levando-as ao varejo.

A quantidade da droga, não deixa dúvida de que à traficância se destinava.

Registro que o depoimento dos policiais no sentido da apreensão da droga em poder do réu reproduz, com fidelidade, o quanto afirmado no depoimento prestado na Delegacia de Polícia, dando conta do ocorrido na data dos fatos.

A propósito da questão, pacífico nos tribunais, inclusive nos superiores, que "O

depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos." (STJ AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013).

Ressalta-se que os agentes policiais, no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos, a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância.

Em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

Não há razão para duvidar da palavra dos policiais que prestam serviço público de enorme utilidade à sociedade, mormente porque seus depoimentos encontram escoro nas demais provas idôneas produzidas nos autos.

O Estado credencia os policiais para o exercício da repressão criminal outorgando-lhes certa parcela do poder estatal e o Judiciário empresta essa mesma credibilidade quando chamados a prestar contas do exercício de sua função.

Sob outro enfoque – agora com os olhos voltados às teses defensivas – de se aduzir que o fato de o réu negar o tráfico não é razão bastante para a pretendida absolvição.

É certo que muitas das vezes os réus tentam defender-se valendo-se da mentira e do engodo, visando a enganar o julgador na busca da absolvição.

No caso em comento a versão apresentada está escoteira nos autos, desacompanhada de qualquer outro elemento que pudesse aboná-la, a par de ser flagrantemente mendaz.

A narrativa apresentada carece de sentido e razoabilidade, segundo foi narrado, sua filha encontrou o ex-namorado, que estava de moto e com algumas sacolas, e pediu que ela levasse referidas sacolas (com quase um 1 kilo de cocaína, droga de elevado valor) – sendo que ela estava a pé – e, enquanto andava pela rua, o réu a avistou e ofereceu carona. Tal versão é inverossímil, tendo o nítido de ludibriar o juízo.

O que se verifica, mais uma vez, é uma tentativa desesperada de atribuir a outrem a responsabilidade que é do réu, desviado em sua conduta, valendo-se de meios ilícitos e ilegais para obter dinheiro fácil.

Ademais, os depoimentos da filha e do filho do réu deve ser recebidos com natural reserva, pois óbvio o pleno interesse na absolvição dele.

Além disso, em nenhum momento na delegacia tal história foi ventilada, não socorrendo a eles a alegação de que na delegacia foram coagidos a contar a história da maneira como posta.

O réu era, na data dos fatos imputável. Tinha pleno conhecimento da ilicitude da conduta praticada e preferiu agir contrariamente à lei.

A prova é certa, segura e dá conta da prática do crime pelo réu, que deve responder pelo delito praticado.

Estabelecida a responsabilidade do réu, passo à dosimetria da pena, com fundamento no artigo 68, do Código Penal, atento ao critério trifásico desenvolvido por Nélson Hungria e obediente à individualização da pena.

Na primeira fase impende observar a regra do artigo 42, da Lei 11.343/2006, pelo

qual preponderam sobre o artigo 59 a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente.

A natureza da droga e sua quantidade principalmente pesam em desfavor do réu, pois se trata de quase 1 kg de cocaína, a justificar o aumento da pena-base.

No que se refere à personalidade do agente - que no entender de Guilherme Nucci é aquela que está vinculada às qualidades morais, às distorções de caráter, à índole do sujeito, que são extraídos de sua forma habitual de ser, agir e reagir (in Individualização da pena, RT, 2005, p. 207) - se mostra negativa.

Isso porque resultou claro que o réu mentiu em Juízo quando alterou a versão dos fatos ocorridos, trazendo exposição falsa acerca de como se passaram os fatos, visando a uma injusta absolvição. Essa atitude demonstra a distorção de caráter e a ausência de senso moral por parte do réu, que se vale da mentira com o propósito de impor tumulto à instrução processual e, maliciosamente, induzir em erro o julgador, com afronta à dignidade da justiça.

Sobre a questão, oportuno ressaltar que ainda que seja o interrogatório um meio de defesa e de prova, evidente que o réu deva respeitar as limitações impostas pelas regras do processo, especialmente aquelas decorrentes da lealdade, da ética, da boa-fé, não se podendo esquecer que o processo é um instrumento para a realização da Justiça, dotado de uma série de formalidades que, em ultima ratio, são verdadeiras garantias para o réu, como também para a sociedade.

Ora, é forçoso reconhecer que o réu ao mentir deliberadamente extrapola os limites da autodefesa - que não é absoluta - demonstrando torpeza e deslealdade processual, expondo a risco a Justiça que pode, em razão de seu proceder, proferir decisão equivocada e, assim, injusta.

Afigura-se evidente que não se pode tolerar que o réu se valha de engodos, ardis e mentiras visando a escapar de uma justa condenação. O acusado que assim age, frauda a produção de provas e torna o processo uma chicana pessoal e egoísta, revelando sua personalidade dissimulada, amoral, o que justifica a elevação da pena.

Acerca do tema, pertinente o registro da lição de Andrey Borges de Mendonça (Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais, 2011, Método, p. 194): "Parece-nos, assim, que se o juiz constatar que o réu mentiu, poderá considerar tal circunstância no momento da pena. Não é que se esteja estimulando a confessar - até porque para isto já há uma circunstância atenuante genérica -, mas apenas negando que ao juiz e ao Poder Judiciário possa se admitir que o réu venha em juízo e, perante um agente do Estado, possa mentir livremente, como se isto fosse algo normal e aceitável, como se entende atualmente".

O entendimento acima explicitado, ainda que minoritário na jurisprudência, tem sido prestigiado em várias decisões judiciais, cabendo o registro, por todas, de parte do judicioso voto da lavra do Desembargador José Raul Gavião de Almeida, na Apelação 00771651-20.2015, da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgada em 30 de novembro de 2017 :

"...Se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexatidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a verdade"

Ainda sobre o tema, se revela oportuno registrar parte do artigo " A mentira do réu como elemento relevante na dosagem da pena", da lavra do Promotor de Justiça do

Estado de São Paulo, Dr. Cleber Pereira Defina, que de forma judiciosa analisou o tema:

"...assim como a confissão dos fatos denota aspecto louvável da personalidade do agente, pois atua com boa-fé e consciência social, o inverso também é verdadeiro: a mentira do agente sinaliza aspecto censurável de sua personalidade, pois atua com má-fé e franca ausência de consciência social, constituindo-se, portanto, em dado sensível quando da individualização da pena. O indivíduo que mente à autoridade só pretende beneficiar-se com a própria torpeza, conduz ao indesejável erro judiciário, prejudica o direito das vítimas e mina a justiça. Este cenário ratifica a deformação dos valores carregados pelo acusado pinoquista, repercutindo em necessidade ainda maior de reconstituição da tábua de valores socialmente almejada em relação ao acusado enganador. Ora, se é justo que a postura de lealdade do imputado deve surtir efeito no sentido de diminuir sua reprimenda, porque atrelada a condições favoráveis de sua personalidade, segue-se clarivamente que há mesma justiça em extrair efeito no sentido de agravar a reprimenda do réu que ostenta péssima personalidade caracterizada pela insolência de mentir perante as autoridades que colheram sua versão dos fatos, especialmente quando a este acusado lhe foi garantido o direito ao silêncio. Aliás, onde o silêncio for útil, não se justifica a mentira. O mesmo Estado que garante ao processado o direito ao silêncio, a possibilidade de não se autoincriminar, que pode criar recompensas para este falar, como é o caso da atenuante da confissão e do acordo da delação premiada, também deve poder intensificar a reprimenda daquele que ousa falar com o exclusivo propósito de enganar e promover injustiça. O embuste, tanto quanto a lealdade, é vetor a moldar a pena justa, pois ambos dizem respeito à personalidade refletida do agente"http://www.esmp.sp.gov.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/148/68).

Em suma, todo acusado tem o sagrado e inafastável direito ao silêncio, que decorre da garantia democrática de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (*nemo tenetur se detegere* ou *privilege against self incrimination*); contudo, tal direito não pode admitir a interpretação que alguns lhe emprestam de tornar aceitável, ou pior, irrelevante, a conduta comissiva de mentir, que é vil, antiética e contrária aos valores mais comezinhos da sociedade, ao revés, deve o julgador, por ocasião da individualização da pena, caso constatado que o réu mentiu ao ser interrogado em juízo, fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo, amparado na personalidade negativa do acusado, pois evidente a ausência de senso moral, denotando índole desviada e personalidade distorcida, daquele que podendo se calar opta deliberadamente por mentir em juízo.

Não se pode olvidar, ainda, que o réu, desde a promulgação da Lei 11.719/2008, é interrogado após a colheita de todas as provas, inclusive depoimento das testemunhas, de forma que tem plena consciência das provas produzidas e da sua repercussão, mormente em razão da defesa técnica que o assiste, razão pela qual a sua opção pela mentira se mostra ainda mais censurável, cínica e abjeta, pois abre mão do direito ao silêncio, e até mesmo da atenuante da pena da confissão, para tentar induzir em erro o juízo e assim ferir a dignidade da justiça.

A propósito, impende registrar, por relevante, que caso o julgador não aumente a pena do acusado mendaz, "estará incentivando o réu a sempre mentir, afinal, se sua mentira não lhe causa qualquer prejuízo, podendo, inclusive, livrá-lo de uma condenação justa, por que confessar um crime ou mesmo ficar em silêncio? Não punir o acusado mentiroso, aliás, viola o princípio da individualização da pena, pois equipara equivocadamente a situação do réu que fica em silêncio em seu interrogatório, com a do que mente descaradamente, em verdadeira afronta à dignidade da Justiça, pois tem o único propósito de induzir esta em erro, minando, assim, sua credibilidade perante a sociedade" ("A mentira do réu e a Dosimetria da Pena", artigo de autoria do Promotor de Justiça, Dr. André Wagner Melgaço Reis,

publicado na rede mundial de computadores, no endereço <http://www.cartaforense.com.br/autor/andre-wagner-melgaco-reis/958>).

Nesse passo, cabe trazer recentíssima decisão proferida pelo voto do i. Desembargador Tetsuzo Namba:

“...demais disso, se eles tinham a opção de confessar ou ficar em silêncio, no momento que se pronunciavam, suas palavras devem ser ponderadas, se mentem, como no caso dos autos, isso não pode ficar sem avaliação valorativa negativa, sob pena de deixar de lado quem, muitas vezes, colabora com a Justiça e diz a verdade, seria o patrocínio indevido da “não verdade”, isso mostra o caráter de alguém, flagrado no cometimento de infração penal, não se arrepende, ao contrário, faz de tudo para se livrar das imputações... (TJSP – Apelação Criminal 0001611-29.2018.8.26.0625, 8.^a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 28.11.2019).

Cabe anotar que o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento recente, por votação unânime, decidiu no mesmo sentido da tese que ora se adota, trazendo excertos de decisão proferida por este juízo como razão de decidir, como se infere dos autos da Apelação nº 0000129-67.2018.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Roberto Porto:

“Ademais, como bem destacou o Ministério Público a fl. 277 o fato de o réu ter mentido em Juízo, trazendo aos autos fatos absolutamente inverídicos, revela sua personalidade desvirtuada, devendo ser considerado no momento da exasperação da reprimenda. Aliás o Douto Magistrado bem fundamentou a exasperação da pena-base...”

No mesmo sentido já decidiu a Colenda 14^a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime nos autos da apelação nº 0000640-36.2016.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Walter da Silva:

“(...) Em relação ao delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03: Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a pena base foi bem fixada acima do mínimo legal, fundamentando o douto Magistrado na personalidade negativa do apelante, pois demonstrou perante o Juiz desonestidade e insinceridade, o que revelou a distorção de caráter, e assim a reprimenda foi tornada definitiva na ausência de outras causas modificadoras.”

Ainda sobre a mentira do réu como circunstância desfavorável, com enfoque na personalidade desviada, em voto proferido pela 6.^a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, pela voz do ilustre relator Zorzi Rocha, assentou:

“Dessa forma, se o réu mentir em seu interrogatório, negando a prática do crime por ele cometido, ou explicando o crime ao apresentar uma versão fantasiosa do fato, tudo a fim de se obter uma injusta absolvição, justificado está o aumento de sua pena-base com fundamento na personalidade negativa. Afinal, a insinceridade e a desonestidade demonstradas perante o Juiz – como explanado no item 2 suso exposto – revelam distorção de caráter e ausência de sendo moral por parte do Réu, que se utilizou da mentira – subterfúgio repugnado pela ética e pelo dever de lealdade – com nítido propósito de tumultuar a instrução processual e induzir em erro o julgador, afrontando, assim, a dignidade da Justiça” (TJSP – Apelação Criminal 0001317-32.2017.8.26.0618, j. 3.10.2019).

Não outra a conclusão a que chegou o ilustre Des. Ricardo Sale Júnior, chamando atenção para a correção do decisor que elevou a pena-base pelo fato de haver o réu mentido ao ser interrogado em juízo “fato que evidencia uma personalidade voltada para o crime” (TJSP – Apelação Criminal 0002205-19.2013.8.26.0625, 15.^a Câmara de Direito Criminal, j. em 8.8.2019).

No mesmo sentido o voto da lavra do ilustre Des. Tetsuo Namba, ao aduzir correta a sentença que reconheceu a mentira do réu como personalidade deturpada, justificando-se a elevação da pena na primeira fase da dosimetria. (TJSP – Apelação Criminal 0001091-27.2017.8.26.0618, 8.^a Câmara de Direito Criminal, j. em 5.12.2019).

Também em processo que teve trâmite por esta 3.^a Vara, em sede de apelação (Apelação Criminal nº 0000037-05.2017.8.26.0625), a i. Desembargadora Ivana David, assentiu com a tese ora perfilada, nos termos seguintes, fazendo alusão, em parte, à decisão proferida nos autos do Processo Criminal nº 0003339-30.2014.8.26.0372, 1.^a Vara Judicial de Hortolândia - Juiz de Direito, Luis Mário Mori Domingues j. 21.01.2015.

“E escorreita a majoração praticada, uma vez que ao mentir em juízo, a acusada foi muito além do seu direito ao silêncio, mentindo para a Justiça, tentando se esquivar das consequências dos seus atos, porquanto, “nosso ordenamento jurídico, amparado por tratados internacionais e na linha de todos os demais sistemas penais do mundo garantem ao acusado o direito ao silêncio. Significa dizer que o réu, silenciando-se, não pode ser acusado com base nesse fundamento, isto é, ausente provas contra o réu, ele não pode ser condenado porque ficou em silêncio. Em momento algum o direito ao silêncio confunde-se com direito a mentira. O silêncio é uma conduta passiva, fundada no direito de não produção de prova contra si. A mentira é conduta ativa, é a produção de prova falsa em juízo”, demonstrando, com isso, além da má índole, que o crime não constituiu um episódio acidental em sua vida. (Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 10.12.2019).

No que respeita à culpabilidade o que se vê é natural à espécie.

Ostenta o réu maus antecedentes pelos processos 33311-41.2009 e 22194-60.2003, da 2.^a Vara Criminal de Taubaté, e 146/03, desta 3.^a Vara Criminal de Taubaté, além de ser reincidente pelos feitos número 14637-85.2004, da Vara do Júri, 15712-62. 2004 e 14951-31.2004, da 1.^a Vara Criminal de Taubaté, o que será aferido no momento apropriado.

Acerca da conduta social do réu não há elementos para que se proceda à sua valoração.

Quanto aos motivos do crime e as circunstâncias, nada há de relevante.

O sujeito passivo do tráfico de drogas é a coletividade, titular do bem jurídico saúde pública, não havendo falar-se em comportamento da vítima.

Assim, partindo da pena mínima em abstrato, em razão da quantidade de droga, personalidade negativa do réu e dos 3 processos que compõem os maus antecedentes, acresço 2/5, e fixo a pena-base em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na fixação da pena intermediária, não se vê circunstâncias atenuantes. Observo, contudo, a existência da agravante da reincidência por outros 3 processos (14637-85.2004, da Vara do Júri, 15712-62. 2004 e 14951-31.2004, da 1.^a Vara Criminal de Taubaté), que faz agravar a pena em 1/3, alçando-a para 9 anos e 4 meses de reclusão, além de 933 dias-multa.

Não há causa de diminuição ou de aumento a considerar, resultando fixada a pena definitiva em 9 anos e 4 meses de reclusão, além de 933 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento será o fechado.

Trata-se de condenação pelo cometimento do delito de tráfico ilícito de drogas, crime que denota conduta absolutamente perniciosa à sociedade, sobretudo por

contribuir com a disseminação da substância ilícita entre a população, fato que, por alcançar patamares insuportáveis, coloca em risco, inclusive, a tranquilidade social e a ordem pública, mormente por ser causa mediata de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza patrimonial. Além disso, o tráfico é equiparado a crimes hediondos e merece, desse modo, tratamento mais severo, sendo que a gravidade da conduta também exige maior rigor por parte do Estado.

Some-se a isso as circunstâncias desabonadoras e a multirreincidência do réu a justificar o regime mais gravoso.

Nos termos do artigo 49, §1.º, do Código Penal, o valor do dia multa será de 1/30 avos do salário mínimo praticado à época do delito, pois ausentes elementos para aferição da capacidade financeira do réu, devendo ser atualizado pelos índices de correção monetária da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde aquela data até o efetivo pagamento.

Incabível a substituição de pena, pois a medida seria insuficiente e ineficaz à reprovação do agente e à repreensão do direito. Ademais, levando-se em conta, mais uma vez, a gravidade in concreto do crime, insuficiente seria sua aplicação, com fundamento no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Incabível, outrossim, a suspensão da pena prevista no artigo 77, em razão da reprovabilidade e da perniciosidade da conduta da traficância, bem como por afrontar o espírito da Lei 11.343/06, que em seu artigo 44, veda a concessão de sursis.

Anote-se, ainda, que a despeito da Resolução n 5, do Senado Federal, que suspendeu a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", presente no §4.º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, a conversão e o sursis não se fazem adequados à prevenção e repressão do crime em espécie, pois, como já se decidiu, "os efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas, que acarretam profundas feridas na sociedade atual, revelam a postura indiferente adotada pelo agente com reação à saúde pública, o bem estar social, e as nefastas consequências de seus atos, o que vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, qual seja, 'os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente'" (TJSP, apelação 0026205.40.2008.8.26.0405).

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois inexistente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência.

Mantém-se a prisão, recomendando-se o réu naquela em que se encontra.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que inexistente ilegalidade em vedar ao condenado recorrer em liberdade quando esteve preso cautelarmente durante toda instrução criminal, desde que permaneçam os motivos dessa segregação (STF – HC n. 89824/MS – 1ª T. – unânime – Min. Carlos Ayres Britto – DJe 28/8/2008; STF – HC n. 114536/MG – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 4/12/2012; STJ – HC n. 222002/RJ – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 11/10/2013).

No caso o réu permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo. A infração penal praticada pelo réu é grave e o retorno ao convívio social, neste momento, é inoportuno. Assim, para que a ordem pública permaneça acautelada, é necessária a manutenção da prisão do acusado.

Pontue-se que o réu é multirreincidente, o que denota que as condenações e o cumprimento de penas anteriores não foram suficientes para dissuadi-lo de perpetrar novos delitos, especialmente pelo delito em exame, com cerca de 1 kg de

entorpecentes.

O tráfico é crime de enorme gravidade, nefasto, que dissemina as drogas e deturpa a sociedade, destruindo seres humanos e lares e que ampara todo o mundo da criminalidade.

Nesse contexto, ainda persistem os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a segregação cautelar, agora mantida com base em um juízo de certeza da culpa.

Assim, presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, a teor do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, mantenho a prisão do réu (artigo 387, parágrafo primeiro, do Código de Processo Penal), negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Diante de tal quadro, verificada a necessidade da manutenção da custódia cautelar, resulta cumprido o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Não há dados suficientes para realização da detração da pena, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, cabendo ao juízo da execução, que detém as informações necessárias, analisar oportunamente eventual direito do réu por conta do período que este permanece preso cautelarmente, consoante determina o artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c". Nesse sentido: (HC 169.072/SP, relator Ministro Og Fernandes – 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 10.6.2010).

Declaro o perdimento do automóvel apreendido.

Isso porque o veículo era utilizado para a traficância (a droga foi encontrada em seu interior), o que fundamenta seu perdimento.

Ressalto que o perdimento dos bens relacionados ao tráfico de drogas é medida que se impõe ainda que não se tenha comprovado a sua habitualidade na prática do tráfico, conforme artigo 63, da Lei 11.343/06, que regulamenta o parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, e sua interpretação dada pelo pleno do Supremo Tribunal Federal.

Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 647, em sede de repercussão geral, fixou tese nos seguintes termos: “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.

Segue a ementa do referido julgado:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 647 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO APREENDIDO COM O SUJEITO ATIVO DO CRIME. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO BEM. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXIGÊNCIA DE HABITUALIDADE DO USO DO BEM NA PRÁTICA CRIMINOSA OU ADULTERAÇÃO PARA DIFICULTAR A DESCOBERTA DO LOCAL DE ACONDICIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. O confisco de bens pelo Estado encerra uma restrição ao direito fundamental de propriedade, insculpido na própria Constituição Federal que o garante (art. 5º, caput, e XXII). 2. O confisco de bens utilizados para fins de tráfico de drogas, à semelhança das demais restrições aos direitos fundamentais expressamente previstas na Constituição Federal, deve conformar-se com a literalidade do texto constitucional, vedada a adstrição de seu alcance por

requisitos outros que não os estabelecidos no artigo 243, parágrafo único, da Constituição. 3. O confisco no direito comparado é instituto de grande aplicabilidade nos delitos de repercussão econômica, sob o viés de que “o crime não deve compensar”, perspectiva adotada não só pelo constituinte brasileiro, mas também pela República Federativa do Brasil que internalizou diversos diplomas internacionais que visam reprimir severamente o tráfico de drogas. 4. O tráfico de drogas é reprimido pelo Estado brasileiro, através de modelo jurídico-político, em consonância com os diplomas internacionais firmados. 5. Os preceitos constitucionais sobre o tráfico de drogas e o respectivo confisco de bens constituem parte dos mandados de criminalização previstos pelo Poder Constituinte originário a exigir uma atuação enérgica do Estado sobre o tema, sob pena de o ordenamento jurídico brasileiro incorrer em proteção deficiente dos direitos fundamentais. Precedente: HC 104410, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06/03/2012, DJ 26-03-2012. 6. O confisco previsto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal deve ser interpretado à luz dos princípios da unidade e da supremacia da Constituição, atentando à linguagem natural prevista no seu texto. Precedente: RE 543974, Relator(a): Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, DJ 28-05-2009. 7. O Supremo Tribunal Federal sedimentou que: AGRADO DE INSTRUMENTO - EFICÁCIA SUSPENSIVA ATIVA - TRÁFICO DE DROGAS - APREENSÃO E CONFISCO DE BEM UTILIZADO - ARTIGO 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Impõe-se o empréstimo de eficácia suspensiva ativa a agravo, suspendendo-se acórdão impugnado mediante extraordinário a que visa imprimir trânsito, quando o pronunciamento judicial revele distinção, não contemplada na Constituição Federal, consubstanciada na exigência de utilização constante e habitual de bem em tráfico de droga, para chegar-se à apreensão e confisco - artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (AC 82-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 3-2-2004, Primeira Turma, DJ de 28-5-2004). 8. A habitualidade do uso do bem na prática criminosa ou sua adulteração para dificultar a descoberta do local de acondicionamento, in casu, da droga, não é pressuposto para o confisco de bens, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 9. Tese: É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 10. Recurso Extraordinário a que se dá provimento.” (RE 638491, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017).

Além disso, as circunstâncias do ocorrido não evidenciam boa-fé alguma. Ainda que o automóvel esteja em nome de terceiro, a alegação de que emprestava o automóvel ao réu para que fizesse carreto soa, mais uma vez, inverossímil. Verifica-se que o veículo anteriormente estava em nome da irmã do réu, porém, era ele quem fazia uso em suas atividades ilícitas, tanto que o veículo era procurado pela polícia. Ao que se pode depreender, o trocar de nome no documento serviu apenas para tentar forjar uma situação de licitude, enquanto o réu permanecia com a posse do carro, justamente para a prática do tráfico.

Dessa forma, decreto o perdimento do veículo em questão, destinando-o à União Federal.

Oficie-se ao Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo 1500322-66.2022, com cópia da presente sentença, que interessa para o deslinde daquele feito.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, de acordo com o artigo 804, do Código de Processo Penal.

Posto isso, acolho o pedido formulado na denúncia para condenar o réu Denis Costa

Santos à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, além de 933 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, iniciando-se o cumprimento em regime fechado, recomendando-o à prisão em que se encontra, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, condenando-o, outrossim, ao pagamento das custas no importe de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei estadual 11.608/03. Condeno, ainda, ao perdimento do veículo apreendido.

Após o trânsito em julgado deverá a Serventia levar a efeito as seguintes providências:

- a) intimar o réu para proceder ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal, assim como ao pagamento da taxa judiciária;
- b) oficialiar ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) oficialiar ao IIRGD comunicando a condenação do réu;
- d) expedir guia de execução penal.

R.P.I.

Taubaté, 22 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA